

1501103-52.2019.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito.

Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501103-52.2019.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501103-52.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.185.424/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marconi Alves Pequeno da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

MARCONI ALVES PEQUENO DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, trazia consigo para fins de tráfico 09 porções de cocaína, 35 de maconha, 26 de crack, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agiam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/73) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/12), boletim de ocorrência (fls.13/15), auto de exibição e apreensão (fls.33/34), auto de constatação (fls.35/36), depósito judicial (fls.63/64), exame químico toxicológico (fls.83/87)

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2019 (fls.80), o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.105/108) prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas (fls.180,389) e colheita do interrogatório.(fls.389)

Em debates finais, o Ministério Público insistiu na condenação com fixação da pena

acima do mínimo diante da quantidade de drogas apreendida com afastamento do redutor. (fls.393/400)

A Defesa por sua vez insistiu na improcedência pela fragilidade probatória com tese secundária de fixação de regime aberto em caso de pena inferior a 04 anos, e semi-aberto nos demais casos, com possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos (fls.403/412)

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/12), boletim de ocorrência (fls.13/15), auto de exibição e apreensão (fls.33/34), auto de constatação (fls.35/36), depósito judicial (fls.63/64), exame químico toxicológico (fls.83/87) corroborado pela prova coligida.

Quanto a autoria, o réu disse que saiu com a esposa e todas as ruas tem biqueira, e subiram os moleques correndo, e estava há dois meses na rua, em liberdade condicional, e a polícia subiu atrás, mas não correu, e já haviam alguns que estavam abordados, e Kaio estava descendo. A polícia o abordou, e liberou os demais, e indagaram se já estava solto, e que diante dos antecedentes acabou abordado. Os policiais já tinham localizado a pochete. Não estava com drogas ou pochete. Disse que não iria segurar as drogas. Um dos policiais já lhe perseguia. Na delegacia, não ouviu o que eles falaram.

Kaio disse que desceu na Viela pegou a droga com dois rapazes e a polícia apareceu, e apreendeu todo mundo. Dois rapazes sendo que um deles tinha uma tatuagem de uma metralhadora e outro tinha uma gueixa. Marconi estava subindo a viela. Na delegacia falou que comprou de Marconi pois ficou assustado. Os rapazes correram e a polícia não pegou. Quando a polícia chegou tudo mundo correu. Realmente não pegou a droga com o acusado. Não conhece Marconi. Nunca viu o acusado na rua. Parou de usar drogas. Chegou a ver o réu de vista no bairro. Atualmente trabalha com máquina de terraplanagem. Na delegacia disse que comprou a droga do réu. Estava com medo de ser preso, por isso falou bobagem.

Elielson disse que receberam a denúncia pelo Copom de tráfico no local com característica dos indivíduos, e no local, haviam dois indivíduos um maior e um menor, sendo que o primeiro correu e estava com uma pochete, mas a outra viatura pegou, e ele estava com drogas e dinheiro na pochete, e ele confessou o delito. O menor disse que estava comprando drogas. Disse desconhecer o procedimento de denúncia no Copom, e a informação era apenas de características de vestimentas e não trazia nome. Não conhecia os envolvidos.

A princípio, contrariando as alegações do réu, vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Alias, o acusado não comprovou ou apresentou alegação a contrariar a idoneidade do depoimento policial.

Pelo contrario, o policial mencionou que atenderam a informação do Copom e se dirigiram ao local com as característica física do individuo, e que conferia com as vestimentas do réu, que foi reconhecido em juízo, bem como, abordaram também um adolescente.

Kaio por sua vez na delegacia e na presença do responsável legal confessou que estava comprando drogas e indicou a pessoa do réu, em juízo, mudou seu depoimento apresentando versão similar ao do réu, negando a aquisição de entorpecente do acusado, o que é ate plausível já que residem no mesmo local.

De fato, a mudança de depoimento do adolescente que frise-se na delegacia estava com os responsáveis, apenas indica que não é pessoa dotada de conceitos mínimos de comprometimento com a verdade, pois se a primeira versão era mendaz prejudicou inocente, agora se a segunda for mendaz estaria auxiliando um culpado, ou seja, esta disparidade de depoimentos, afasta qualquer credibilidade ou verossimilhança no depoimento de Kaio, tornando imprestável seu depoimento.

Alias como não é depoimento idôneo, e não influenciou no julgamento torna-se desnecessária a apuração do delito de falso testemunho, ate pelo eventual temor de represália, já que residem no mesmo bairro e adjacências.

Realmente uma testemunha que não tem a capacidade de sopesar o resultado de seus atos, não pode ter o testemunho relevado como prova.

No entanto, alegou o réu que estava com a esposa, a qual não foi arrolada e poderia ter confirmado a versão do acusado, já que era seu o onus desta prova nos termos do artigo 156 do CPP, do qual não se desincumbiu.

Ora, o réu estava com Defensor constituído desde o início do processo, e que tinha ciência da versão do acusado, de modo que poderia ter arrolado a esposa, ate como informante para que esta esclarecesse os fatos, não o fez, o que leva a conclusão que a ausência de oitiva ocorreu pois a versão trazida pelo réu não seria idônea, já que não é amparada pela realidade fática.

Pontua-se que se realmente a esposa do réu estivesse consigo, e presenciando uma injustiça seria a primeira a comparecer na delegacia, a lutar pela verdade, o que seria comum a todos que presenciavam algo indevido, este silêncio da convivente, e sua ausência de arrolamento apenas reforçam que não o fez, pois a versão do réu não tem verossimilhança.

Soma-se ainda que o policial sequer conhecia o réu ou sua vida pregressa, sendo que o acusado sequer conseguiu comprovar que era perseguido pelos policiais, já que não declinou o nome de qualquer dos policiais que participaram da diligencia.

Não se pode deixar de considerar que os policiais mencionaram que a característica do réu era idêntica a recebida pelo Copom, e que ele correu ao ver a viatura e estava com a pochete que realmente foi apreendida com diversidade e quantidade de drogas embaladas além de dinheiro sem origem, não sendo crível que policiais que sequer conheciam o réu trafeguem pela cidade com drogas e dinheiro a esmo para intrujarem em pessoas desconhecidas.

Salienta-se ainda que se realmente a detenção foi irregular como sustentou o réu e com uma combativa Defesa teria efetuado a devida reclamação junto a Corregedoria de Polícia Militar, o que não o fez, ou seja, não tomou qualquer atitude legal a apontar que sua versão era crível, nada fez a afastar a versão do policial, que frise-se sequer conhecia o acusado.

Pelo contrário, o policial em depoimento esclareceu a diligencia, a abordagem do acusado, localização das drogas e dinheiro, não sendo esta versão afastada por documentos, testemunhas, ou outros elementos, permanecendo a versão do réu isolada e divorciada das provas produzidas.

Em suma, as provas acostadas aos autos, somadas a efetiva apreensão de droga, evidenciam a realidade do tráfico exercido pelo réu, na conduta de trazer consigo, e guardar.

Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288).

A lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de

delito de tráfico ilícito.

Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral - Conjunto probatório suficiente à condenação - Pleito visando a desclassificação para o delito de porte de drogas - Impossibilidade - A diversidade, a forma de acondicionamento da droga, sua quantidade, assim como as circunstâncias da apreensão, demonstram, à evidência, que o entorpecente se destinava ao tráfico - Pena e regime corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Des. Borges Pereira)

"A inversão do ônus da prova, uma vez que o trabalho acusatório demonstrou suficientes indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, às defesas indicarem fatos que afastasse, inequivocamente, os seguros indicativos da participação das acusadas no crime." Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessária prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos que cercam o agente infrator podem fornecer o material de convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito, elementos indiciários, como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota de comércio ilícito etc. Erigir-se, como regra, a necessidade de prova direta da finalidade comercial da substância entorpecente em poder do acusado, para fazer incidir o art. 12, por um lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto de vista jurídico constituir-se numa teratologia." (RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001. p. 157).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO-DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel A. Duarte - Julgamento: 8/3/2010) Apelação - Tráfico DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - Interceptação Telefônica PROVIMENTO PARCIAL. Mantém-se a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes quando devidamente caracterizadas a autoria, a materialidade e tipicidade. [...]. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza múltipla, caracterizando-se quando o agente pratica um ou mais dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. (AC nº 1.0384.07.053086-8/001 - Rei. WALTER PINTO DA ROCHA - Data da Publicação: 04/04/2008). É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos carreados, como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração, etc. Nesse sentido, sobre o valor probatório dos indícios, cita-se a lição de Julio Fabrinhi Mirabete, constante no acórdão do ilustre Relator Borges Pereira (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011), a saber: (...) tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária no processo (...) diante do sistema da livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na exposição de motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim,

indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatoria, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado, (in Código Penal Interpretado - Ed. Atlas - SP -1999 - pág. 532). (citado no corpo do acórdão da apelação 0005711-21.2009.8.26.0050,TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Dês. Borges Pereira)

A tudo se some que a circunstância de alguém consumir drogas não significa não pudesse traficar.

Aliás,é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício. Assim já se decidiu:“Igualmente não se desconhece que as testemunhas da defesa informaram ser o réu usuário de entorpecentes. Essa circunstância, porém, não afasta a possibilidade dele traficar. O usuário também pode traficar e, na espécie, nenhuma dúvida existiu quanto à integridade de autodeterminação da ré. Nenhum elemento de convicção existe nos autos a indicar pudesse o crime ser praticado em razão da alegada dependência da acusada à maconha” (Apelação criminal nº 962.226-3/8).

Não se olvide que o réu trazia quantidade significativa de drogas diversas devidamente embaladas e prontas para a venda, o que confirma o trafico de drogas, já que somado a quantia em dinheiro sem qualquer comprovação de origem.

Desta forma a procedência da ação é de rigor. Passo a dosimetria da pena.

Esclareço que a diversidade e quantidade de entorpecentes, é analisada na fixação da pena com arbitramento da reprimenda acima do mínimo legal, já que mostra uma maior desvalia da conduta.

Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada” (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). “A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (STF - RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.).

Ainda, o réu é portador de maus antecedentes, e estava em liberdade condicional descumprindo condições benéficas, ou seja, insistiu em conduta delituosa, o que reforça a má conduta social, portanto, diante destas circunstâncias fixo a pena em 2/5 acima do mínimo, ou seja, 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Presente a agravante da reincidência que é especifica conforme certidão a fls.376, o que eleva a pena em 1/3, totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento

de 933 dias-multa. Ausentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena não se aplicando o redutor já que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes não preenchendo os requisitos legais.

Nesse sentido: "Não bastasse, a expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (147 eppendorfs (133,4g), contendo cocaína; 99 invólucros plásticos (239,9g) contendo maconha; 67 pedras (13,7g) de crack; e 02 sacolas (1.200,2g), contendo cocaína em pó) mostra-se como circunstância idônea para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma vez denotadora de que o agente, para ter acesso a elas, detém fidúcia junto ao fornecedor e incorporou-se à organização criminosa, ou, no mínimo, têm se dedicado frequentemente à traficância, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013 - extraído do Acórdão Apelação Criminal nº 1509502-20.2019.8.26.0228, relator Desembargador Amaro Thome, de 01/09/2020) Ainda: "DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, conseqüentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020). Ademais, a consideração da quantidade, natureza e variedade de entorpecente apreendido para aumentar a pena-base e, concomitantemente, afastar a aplicação da referida minorante não configura indevido bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (HC nº 578.872 Relator Ministro Joel Ilan Paciornik julgado em 04/08/2020)

Fixo a minguada de outro elemento o dia -multa no mínimo legal.

O réu é reincidente, portador de maus antecedentes, e estava em liberdade condicional quando se envolveu nesse novo delito, o que mostra que ainda não estava reeducado e reintegrado socialmente, indicando que regime mais brando não é suficiente. Ademais pela pena aplicada e pelas condições subjetivas negativas o único regime cabível, é o fechado.

A questão da detração deve ser analisada no juízo cabível, já adiantando que o tempo em que esteve preso não atingiu ainda o limite para alteração de regime prisional.

"O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade (...)." (TJSP, AP. 0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, jg. 24/01/2017).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de tráfico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminosa, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pontua-se ainda que a pena superam o limite legal, bem como, existe a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, além da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões. "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 33 caput da lei 11343/06 o reu MARCONI ALVES PEQUENO DA SILVA a pena privativa de liberdade de 09(nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 933(novecentos e trinta e três) dias-multa cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc)..

Custas pelo acusado nos termos da lei.

O réu se encontra solto agraciado por decisão em Habeas Corpus, sendo que ao que parece vem cumprindo com as medidas cautelares e atos processuais, de modo, que defiro o recurso em liberdade mantendo as cautelares a fls.280

Decreto o perdimento do dinheiro já que advindo de origem ilícita.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se com as comunicações de praxe, informando o IRGD e a Justiça Eleitoral, e providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe.

Sao Roque, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA